

《【문제1】 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스크관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스크관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50점)

(물음1) 위와 같은 소송형태의 적법 여부와 이에 대한 법원의 조치 및 판단에 대하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 피고를 특정하여 소를 제기한 후 예비적으로 피고를 추가한 소송형태의 적법 여부와 법원의 조치

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 A은행의 부서장인 리스크관리본부장 乙을 피고로 특정하여 퇴직금 관련 청구를 제기한 후 법률적 불확실성을 이유로 예비적으로 A은행을 피고로 추가한 상황이다. 쟁점으로 <피고 특정의 적법성과 예비적 피고 추가 형태의 허용 여부 및 이에 대한 법원의 심리·판단 방법>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 잘못 지정된 피고와 예비적 피고 추가의 소송형태에 관한 법리 및 법원의 조치와 판단에 대해 논한다.

II. 예비적 공동소송과 피고 추가의 법정 요건

1. 주관적 예비적 공동소송의 요건

(1) 의의 및 취지

- 공동소송인 일부에 대한 청구가 다른 공동소송인에 대한 청구와 법률상 양립할 수 없는 경우를 주관적 예비적 공동소송이라 한다. 이는 재판의 모순·저축을 방지하고 분쟁을 한꺼번에 해결하기 위한 제도이다.

(2) 법률상 양립 불가능성

- 양립할 수 없는 관계란 한쪽 피고에 대한 청구가 인용되면 타방 청구는 당연히 기각되는 관계를 뜻한다. 실체법상 채무의 귀속 주체가 누구인지 불분명하여 모순되는 주장을 하는 경우 등이 이에 속한다.

2. 예비적 피고 추가의 적법성

(1) 피고 추가의 허용 여부

- 민사소송법 제70조 제1항은 예비적 공동소송에 필수적 공동소송인 추가에 관한 제68조를 준용한다. 따라서 소송계속 중 예비적 피고를 추가하는 후발적 피고 추가도 적법하게 인정된다.

(2) 추가의 시기적 한계

- 피고 추가 신청은 제1심의 변론을 종결할 때까지만 할 수 있다. 항소심 단계에서의 예비적 피고 추가는 피고의 심급의 이익을 해칠 우려가 있어 원칙적으로 허용되지 않는다.

III. 피고 추가 신청에 대한 법원의 조치

1. 피고 추가의 신청과 허가

(1) 원고의 신청

- 원고가 기존 피고 외에 다른 사람을 예비적 피고로 추가하고자 할 때에는 서면으로 신청하여야 한다.

(2) 법원의 허가결정

- 법원은 추가 요건을 심사하여 적법한 경우 제1심 변론종결 전까지 결정으로 피고 추가를 허가한다.

2. 허가결정에 따른 송달 및 소급효

(1) 정본 및 부분의 송달

- 법원은 허가결정을 한 때에는 결정 정본을 당사자 모두에게 송달하여야 하며, 추가될 피고에게는 소장 부분도 송달하여야 한다.

(2) 소제기의 소급효

- 추가된 피고에 대한 관계에서는 처음의 소가 제기된 때에 소가 제기된 것으로 간주되므로 시효중단 등의 효력이 소급하여 발생한다.

IV. 예비적 공동소송에 대한 법원의 판단

1. 심판의 범위와 전부판결의 의무

(1) 심판 대상의 범위

- 민사소송법 제70조 제2항에 따라 주위적·예비적 공동소송에서는 모든 공동소송인에 관한 청구에 대하여 판결을 하여야 한다.

(2) 일부판결의 금지

- 법원은 일부 피고에 대해서만 판단을 내리고 누락하여서는 안 되며, 누락 시 일부판결 금지 원칙에 위배되어 부적법하다.

2. 주위적 피고와 예비적 피고에 대한 개별 판단

(1) 주위적 피고 乙에 대한 판단

- 리스크관리본부장은 은행 내부 기관에 불과하여 당사자능력이 없다. 乙 개인에 대한 소로 보더라도 퇴직금 지급의 실체법상 의무자가 아니므로 피고격이 없어 소각하 또는 청구기각 판결을 내려야 한다.

(2) 예비적 피고 A은행에 대한 판단

- A은행은 법인으로서 당사자능력 및 퇴직금 지급의 실체법상 의무를 부담하는 피고격자이다. 따라서 법원은 乙에 대한 소를 배척함과 동시에 A은행에 대한 청구의 존부를 실질적으로 심리하여 판결해야 한다.

V. 사안의 적용

1. 소송형태의 적법성 판단

(1) 양립 불가능성 충족

- 퇴직금 지급의무자가 乙 개인인지, 아니면 법인인 A은행인지 여부는 법률상 양립할 수 없는 관계이므로 주관적 예비적 공동소송의 요건을 구비한다.

(2) 피고 추가의 적법성

- 원고 甲이 제1심 소송 계속 중에 A은행을 예비적 피고로 추가한다는 취지의 준비서면을 제출한 것은 제1심 변론종결 전의 서면 신청으로 적법한 피고 추가 신청이다.

2. 법원의 조치 및 판단의 대입

(1) 법원의 허가 및 송달 조치

- 수소법원은 甲의 신청을 피고 추가 신청으로 다루어 허가결정을 내려야 한다. 허가결정 정본을 乙과 A은행에 송달하고, A은행에는 소장 부분도 함께 송달하여 절차를 마쳐야 한다.

(2) 전부판결의 수행

- 법원은 乙에 대한 청구와 A은행에 대한 청구 모두를 판단하여야 한다. 당사자능력이 없는 乙에 대한 청구는 각하하되, 예비적 피고인 A은행에 대해서는 본안을 실질적으로 심리하여 판결한다.

VI. 결론

- 원고 甲이 乙을 상대로 제기한 소송 중 A은행을 예비적 피고로 추가한 소송형태는 법률상 양립 불가능한 공동소송 및 피고 추가 요건을 충족하므로 적법하다. 법원은 피고 추가 허가결정을 내리고 정본과 소장 부분을 송달하여야 한다. 또한 전부판결 원칙에 따라 乙에 대한 청구를 각하·기각함과 동시에 예비적 피고인 A은행에 대한 청구를 판단하여야 한다.